

1504547-38.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504547-38.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504547-38.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2053174/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 23218285 - 33º D.P. PIRITUBA, 856/22/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 2053174 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL BARBOZA GONCALVES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

GABRIEL BARBOZA GONÇALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Isso porque, no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 09h15min, na Rua Núcleo Bandeirante, nº 1-A, Pirituba, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, o acusado foi surpreendido trazendo consigo, para entrega ao consumo de terceiros, drogas consistentes em 11,6g (onze gramas e seis decigramas) da substância cocaína na forma de crack, bem como 5g (cinco gramas) da substância cocaína em pó, sem autorização e em desacordo com determinação legal e Regulamentar. Narra a denúncia que o denunciado estava no local dos fatos trazendo consigo, para

fins de tráfico, as porções de drogas acima descritas, as quais eram mantidas no porta óculos que ele carregava. Na ocasião dos fatos, enquanto comercializava os supracitados entorpecentes, GABRIEL percebeu a aproximação de policiais militares e empreendeu fuga a pé, dando início a breve perseguição. Durante a tentativa de fuga, o denunciado acabou caindo ao solo e derrubou o mencionado porta óculos, que foi recuperado pelos Policiais.

Em seguida, GABRIEL foi submetido a revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Entretanto, ao abrirem o porta óculos que ele trazia consigo, os policiais encontraram 83 (oitenta e três) porções de crack e 6 (seis) porções de cocaína. Indagado, o denunciado confessou informalmente que estava traficando aquelas drogas naquele local. Interrogado na Delegacia de Polícia, GABRIEL permaneceu em silêncio.

Oferecida a denúncia de fls. 1/3, foi ela recebida no dia 28 de abril de 2022 (fls. 91/94). Consequentemente, o acusado foi citado (fls. 83), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 87/88). Inviável a absolvição sumária, designei audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de maio de 2022 (fls. 91/94). Encontram-se nos autos ainda o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 6/8; 9/10); o auto de prisão em flagrante (fls. 4/5); bem como a folha de antecedentes do acusado (fls. 31/32 e 68/70).

Na data de hoje, realizada a audiência de Instrução, Debates e Julgamento, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denuncia e o réu interrogado ao final. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denuncia sem possibilidade de se reduzir a pena diante de seu passado, duas passagens por trafico de drogas quando ainda adolescente. Regime fechado. A Defesa deixa de sustentar o pleito absolutório em razão da confissão do acusado. Requer a fixação da pena em seu mínimo. Ele é tecnicamente primário e de bons antecedentes. Requer a possibilidade de reconhecimento da atenuante inominada, considerando-se a situação familiar do acusado

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls.13) e dos laudos de constatação provisória (fls.15/18), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substancia entorpecente (fls.112/114), com resultados positivos para COCAÍNA.

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva.

RODRIGO policial militar reconhece o acusado de uma prisão por traficx. É sargento da Força tática e em um pono conhecido de trafico viram duas pessoas sentadas atrás de um veículo. Eles correram em direção a uma viela. Como já conhecem o local, dois policiais desembarcaram e os demais continuaram na viatura. Foi um dos que desembarcou e já na viela, os dois estavam correndo em direção aos poliias e deram meia volta. Ocorre que gabriel caiu mas antes ele tentou se livrar de um porta óculos ondelocalizou entorpecente. Ele admitiu que estava no trafico e que o outro iria substitui-lo no turno. Ele teria trabalhado a noite toda. Dinehiro não foi apreendiao. Ele foi levado para o hopital em razçaiio das escoriações e depois ao delpol. 83 pedras de crack e 6 de cocaína. Ele estava sem documentos então foram a casa dele ali nas proximidades. Reconhe ce a fotografia de fls. 18 como sendo o objeto o saco e as drogas que estavam nas mãos dele e que caiu das mãos dele provavelmente por conta da queda. Não chegou esse objeto durante a perseguição. Policial Thiago recorda-se de Gabriel. Estava em patrulhamento de Força Tática em local já conhecido como de venda de entorpecente. Viu dois individuos que ao visualizar os polciias passaram a fugir em direção a uma viela. Desembarcou da viatura junto com o Comandadnte. Entrou na viela e encontrou os dois na viela o réu

acabou caindo e com ele estava um porto óculos com entorpeente, crack e cocaína. Viu o porta óculos nas mãos de gabreil que caiu de suas mãos quando ele tropeçou. Ele admitiu os fatos e declarou que o estava passando para o outro que iria assumir o turno na atividade ilícita.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuísse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). Além de toda a prova oral colhida, idônea a fundamentar o decreto condenatório, temos a confissão do acusado obtida em juízo, vejamos.

Gabriel declarou que tem 19 anos de idade. Mora com a mãe, avó, sobrinho, irmã, tio e primo. Está desempregado e não estuda. Trabalhava em um lava rápido. Responde a um processo de receptação. Reconhece que estava trabalhando no tráfico. Estava desempregado porque o dono não estava em condições de pagar. A mãe tem câncer de mama a irmão tem problemas e os amigos disseram que essa seria uma forma rápida de ganhar dinheiro. Admite tudo que foi dito. Na Infância passou por dois tráficos, um foi forjado e o outro reconhece.

Daí porque, confrontados os elementos de prova, afigura-se de rigor a condenação. Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, a confissão e a menoridade relativa não serão utilizadas para o fim de se diminuir a pena aquém do mínimo legal.

Em terceira fase, pesem as ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui maus antecedentes, fls.34. Entendo inviável, nesta fase processual, considerar-se suas anotações decorrentes da época em que era adolescente mesmo porque a certidão de fls. 35 nada comprova e suas declarações quanto a possível prática de ato infracional não autoriza a presunção do reconhecimento da prática ilícita com trânsito em julgado. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse

organização criminosa apenas porque estivesse na posse de pouco menos de 17 gramas de entorpecente. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a prática delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno GABRIEL BARBOZA GONÇALVES DA SILVA, RG: 39631905, nascido em 05/08/2002, natural de São Paulo - SP, filho de Nelson Gonçalves da Silva e Eliane Aparecida Albano Barboza, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, “caput” e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato.

Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão

das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;

Transitada esta em julgado tornem conclusa para a designação de data para audiência admonitória.

Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado.

Isento de custas.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA